

1503619-23.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... nesse viés:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE – RELATO DOS POLICIAIS QUE CONFIRMOU O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E QUANTIDADE DA DROGA QUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503619-23.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503619-23.2021.8.26.0196

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

20251542 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 8700/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2250872/2021

- DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL ANDRADE DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

SAMUEL ANDRADE DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, segundo acusação, no dia 14 de setembro de 2021, às 22h16, na Rua Mário José Pereira, nº 100, bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo drogas, a saber, 3,27g (três gramas e vinte e sete centigramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de trinta e seis porções de substância em pequenos fragmentos, de cor bege, embalados individualmente em papel alumínio e 6,41g (seis gramas e quarenta e um centigramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de uma porção de substância de aspecto vegetal, compactada, de cor esverdeada e marrom, embalada em invólucro plástico branco, com

finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O pedido foi instruído com inquérito policial e o auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 99).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 15 de setembro de 2021 (fls. 58/62).

Foi concedida a liberdade provisória ao réu em 16 de setembro de 2021 (fls. 85).

O réu foi notificado (fls. 118) e apresentou defesa prévia (fls. 125).

A denúncia foi recebida em 7 de janeiro de 2022 (fls. 126).

O réu foi citado (fls. 155).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, bem como o interrogatório do réu.

Em memoriais, o Ministério Público postulou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Destacou a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu. Ressaltou a reincidência do acusado. Requereu a fixação de regime fechado para cumprimento de pena.

A defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Destacou que só deve ser admitido como prova aquilo que foi produzido sob o crivo do contraditório. Ressaltou que devem ser consideradas com cautela as palavras dos policiais como prova. Requereu a aplicação do princípio de presunção de inocência. Pleiteou pela desclassificação do delito para o de porte de drogas para consumo pessoal e consequente atipicidade da conduta. Suscitou a impossibilidade de afastamento da minorante de tráfico privilegiado com fundamento na existência de ato infracional. Na dosimetria, pediu a fixação da pena base no mínimo legal. Requereu a consideração da atenuante da menoridade relativa. Pleiteou a fixação de regime aberto e a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. Por fim, postulou pelo direito do réu em apelar em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem corrigidas, passo ao julgamento do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação provisória (fls. 20/26) e exame toxicológico (fls. 119/121), bem como pela prova oral colhida.

Quanto aos entorpecentes, concluíram os senhores peritos que nos materiais apreendidos "DETECTADA a presença de METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloides extraídos do vegetal *Erythroxylon coca* L", e "DETECTADA a presença TETRAHIDROCANABINOS (THC), princípio ativo do vegetal "*cannabis sativa* L" (fls.120).

A autoria do crime de tráfico também restou perfeitamente delineada. Vejamos:

O policial militar Jefferson Alexandre Salviatto disse que estava em patrulhamento na periferia da cidade. Passou um veículo com o porta-malas aberto e com o interior cheio de fios. Foram abordados os ocupantes e dois deles já eram conhecidos no meio policial pela prática de furtos. No interior do bolso de Samuel Andrade havia as porções de drogas que foram apreendidas. Não conhecia o réu até então, que disse não residir em Franca. Indagado a respeito, o réu disse que a droga era sua e iria vender a droga pelo valor de R\$10,00 cada porção.

No mesmo sentido o depoimento extrajudicial do policial militar Eder Jofre de Oliveira.

Nesse ponto, não há que se falar em desconsideração ou relativização da força probatória da palavra policial no processo penal. Isso porque, de acordo com diversos precedentes judiciais, a relativização da força probatória a eles atribuída somente deve acontecer quando houver indícios de falsa imputação de delito ao acusado – em razão, por exemplo, de perseguição policial ou inimizade –, o que não se verificou no caso em comento.

Em casos similares, assim tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida – (...) (TJSP; Apelação 0000049-45.2013.8.26.0597; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

Consigne-se que em casos como o dos autos, que envolvem tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos agentes estatais que tem o dever legal de preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Com efeito, apesar do depoimento prestado pela testemunha de defesa, em juízo, e o interrogatório do réu serem contrárias às versões declinadas pelos agentes estatais, enfatizo nessa oportunidade, que não há absolutamente nada nos autos que ao menos indique a possibilidade de imputação falsa do delito ao acusado.

Portanto, vislumbro que a negativa trazida pelo acusado ao longo da instrução e a versão dada pela testemunha de defesa não encontram suporte probatório. Vejamos:

A testemunha arrolada pela defesa, Gabriel Ramos, disse que estava dentro do carro abordado. Haviam acabado de comprar o veículo. A compra foi feita por Wallace. O carro já estava com o porta-malas cheio de arame. Iriam usar o produto para fazer uma cerca. Depois foram parados pelos policiais. Demoraram a parar porque o carro estava sem freio. Houve busca pessoal e foi encontrada uma droga em terreno próximo ao local da abordagem. O policial disse que a droga estava no bolso do réu, mas isso não era verdade. Ele trazia apenas uma porção de maconha consigo. O réu disse que a maconha era para uso pessoal, mas não admitiu a venda de entorpecente de forma alguma.

O acusado Samuel Andrade do Nascimento, interrogado em juízo, disse que já respondeu por internação quando menor de dezoito anos, também envolvendo posse de droga. Admitiu que trazia consigo uma porção de maconha, que era para seu uso pessoal. Os policiais encontraram as porções de droga em terreno ao lado do local

da abordagem. Não admitiu a prática de tráfico de drogas. Isso só ocorreu por conta das agressões e ameaças dos policiais em desfavor do acusado. Nunca vendeu drogas depois que sua maioridade.

Extrajudicialmente o acusado confessou a traficância. Disse que iria vender parte da droga apreendida por R\$ 10,00 (fls. 7)

Desse modo, conforme fundamentação supra, destaco que, em situações como a que ora se apresenta, em que presentes divergências entre a conveniente negativa do acusado - acobertada ainda pela testemunha de defesa -, e as firmes palavras dos agentes estatais, resguardando-se a fé pública a eles atribuída, in casu, privilegia-se a última. Ademais, no caso, ainda há que ser considerada a confissão extrajudicial do acusado, a qual vai ao encontro das firmes narrativas dos policiais que realizaram a abordagem.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse viés:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - RÉU PRESO EM FLAGRANTE - RELATO DOS POLICIAIS QUE CONFIRMOU O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E QUANTIDADE DA DROGA QUE NÃO SE COADUNA COM USUÁRIO. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA ADEQUADA, DENTRO DOS PRECEITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000492-73.2018.8.26.0450 - Desembargadora Relatora Ivana David - Órgão Julgador 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do Julgamento 28/6/2020 - Data de Publicação 28/6/2020)

Assim, a apreensão das porções de drogas na posse do acusado, somada ao firme e coerente depoimento do policial, bem como à confissão extrajudicial do réu, afastam a arguição de insuficiência probatória.

Saliente-se que, para a caracterização do tráfico de drogas nem ao menos é imprescindível que a pessoa seja encontrada praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº 11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (g.f.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Pretendida absolvição - Impossibilidade - Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos - Prova segura a ensejar a condenação - Confissão em consonância com as palavras dos policiais - Desnecessidade da prática de atos de mercancia - Condenação irrepreensível - Redução da pena - Descabimento - Inviável a aplicação do art. 33, §4o, da Lei de 11.343/06 - Não preenchimento dos requisitos legais - Réu que se dedicava às atividades criminosas - Regime fechado mantido ante a gravidade em concreto dos fatos - Correção de erro material no dispositivo da sentença - Recurso defensivo desprovido e correção de erro material. (TJSP; Apelação 0000650-28.2018.8.26.0548; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

Outrossim, não assiste razão a defesa em relação à tese do princípio constitucional da presunção da inocência posto que os elementos probatórios são seguros e se corroboram, não havendo qualquer dúvida a respeito da autoria e materialidade delitiva.

No mais, não merece guarida o pedido de desclassificação da infração para o de porte de drogas para uso pessoal.

Ora, a alegada condição de mero usuário, como quer a defesa, não raras vezes se confunde com a de traficante, na medida em que a comercialização da droga se torna meio para sustento do vício. Saliente-se que o argumento do "uso próprio" para se esquivar da caracterização da traficância não tem aptidão de afastar a responsabilização por essa conduta inequivocamente mais grave.

Outrossim, não houve sequer pedido da defesa para instauração de incidente de dependência toxicológica, não restando comprovada a afirmação de "mero usuário", ficando, portanto, afastada qualquer hipótese de desclassificação ou atipicidade do delito.

Por fim, apesar de a combativa defesa ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Por todo o exposto, é medida de rigor a condenação do acusado, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta contra o acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade da agente. Quanto aos motivos, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências, nada há que enseje a majoração a pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime com sujeito passivo representado pela coletividade. Assim, fixo-lhe a pena base no patamar mínimo, nos termos do art. 33, caput da Lei 11.343/06, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante em virtude da menoridade relativa do acusado e da confissão extrajudicial do réu. Todavia a despeito da presença das atenuantes, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual a pena se mantém no mínimo, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

"Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Na terceira fase, apesar do réu já ter respondido por atos infracionais (fls. 35), vislumbro que, no caso concreto, não há como considerá-los para fins de afastar a aplicação do benefício do parágrafo quarto, art. 33 da Lei de Drogas, já que, não há elementos nos autos que comprove a dedicação do acusado em atividades criminosas. Conforme restou comprovado, o acusado não era conhecido dos policiais pelo crime de tráfico. Ele foi abordado pelos policiais, na posse dos entorpecentes, em patrulhamento de rotina, não havendo qualquer denúncia contra ele. Desse modo, considerando a quantidade de entorpecente apreendida e a primariedade do réu, aplico o benefício e reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescente a execução penal. 4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena. 5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (EDcl nos EREsp 1916596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 30/11/2021) (grifamos)

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, e condeno SAMUEL ANDRADE DO NASCIMENTO como incurso no art. 33, caput cc. §4º da Lei 11.343/06 ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Diante da primariedade do acusado e da quantidade de pena aplicada, conforme disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO, visto que o regime inicial fechado, como requereu o Ministério Público, não se mostra adequado ao caso em tela.

Ante os termos do artigo 44 do Código Penal e considerando a quantidade de drogas, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, pelo mesmo prazo da pena corporal e na forma a ser indicada pelo juízo da execução.

Tendo o réu respondido solto a instrução, permito eventual apelo em liberdade.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.

Franca, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA